

1500358-40.2019.8.26.0028

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... conhecido no meio policial por crimes de tráfico de drogas. Não ouviu o Pedro Henrique falar nada acerca do roubo do HB20.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Wagner Ramos argumentou em juízo que; Não conhece bem o réu, mas ele é roleiro de moto. Conta que o acusado deixou o carro em uma das ruas no Parque das Rodovias e disse que podia andar nele, que a chave estava no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, . - São Roque

CEP: 12570-000 - Aparecida - SP

Telefone: (12) 3105-3352 - E-mail: aparecida2@tjsp.jus.br

1500358-40.2019.8.26.0028 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500358-40.2019.8.26.0028

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Henrique Carvalho Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia PEDRO HENRIQUE CARVALHO BARBOSA, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, §2º - A, I, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 26 de abril de 2019, por volta das 11h57, na Travessa Roquinho V, nº 37, no bairro Centro em Aparecida, PEDRO HENRIQUE CARVALHO BARBOSA, vulgo Chaleira, subtraiu para si um Hyundai HB20 1.6M, azul, 2013, placa FEY 7238 - Guaratinguetá/SP, avaliado em R\$34.000,00, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, contra Débora Aparecida Ribeiro Campos.

Apurou-se que, enquanto a vítima estacionava seu veículo na via supra, o DENUNCIADO aproximou-se, exibindo uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo que a ofendida descesse do carro. Diante disso, Débora acionou a buzina, visando chamar a atenção de algum vizinho, porém não recebeu ajuda, tendo, então, pegado a sua bolsa e a chave do automóvel e saído correndo.

Ao notar que a chave não estava no carro, o LIBELADO ameaçou atirar caso ela não lhe entregasse, tendo a vítima indicado o local que havia jogado. Localizada, o

roubador entrou no veículo e se evadiu.

Já no dia 30 de abril, durante patrulhamento ostensivo pela cidade de Lorena, os policiais militares Nilton César Moreira da Silva e Zaqueu Siqueira Azarias localizaram a res em poder de Wagner Ramos, o qual informalmente afirmou que PEDRO HENRIQUE havia deixado o carro consigo.

Na DelPol, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o LIBELADO como o autor do delito.

Denúncia recebida em 09 de dezembro de 2019 (fls. 101/103).

Citado, o acusado ofereceu Defesa Prévia às fls. 142 pleiteando pela instauração de incidente de insanidade mental.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e a testemunha arrolada pela Defesa. Por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada, pela presença da materialidade e autoria delitiva.

A Defesa, por sua vez, pediu pela absolvição do réu, pela ausência de provas, subsidiariamente pleiteou a absolvição imprópria do acusado, tendo em vista que reconhecida sua inimputabilidade ao longo da instrução.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, §2º - A, I, do Código Penal.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A ação penal é IMPROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que pairam dúvidas sobre a autoria delitiva, sendo de rigor a absolvição do acusado.

Vejamos.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

"Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre quando a posse da coisa é invertida.

"O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima". STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.

A materialidade delitiva resultou provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/06), Termo de Declarações da Débora Aparecido Ribeiro Campos (fl. 07), Ordem de Serviço (fl. 08), Auto de Reconhecimento Fotográfico do autor (fl. 09), Relatório do Setor de Investigações Gerais (fls. 10/11), Fotografia (fls. 12) Boletim de Ocorrência da Delegacia de Polícia Civil de Lorena (fls. 13/17), Termo de Depoimento de Nilton César Moreira da Silva e Recibo de Entrega de preso (fls. 18/19), Termo de Depoimento da testemunha Zaqueu Siqueira Azarias (fl. 20), Termo de Declarações de José Adriano Freitas Silvério (fl. 21), Termo de Declarações de Débora Aparecida

Ribeiro Campos (fl. 22), Termo de Interrogatório de Wagner Ramos (fl. 23), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/25), Relatório Final oferecido pela Delegacia de Polícia Civil (fls. 83/85), Laudo Médico (fls. 185/187), bem como pela prova oral colhida.

No que toca à autoria:

A vítima Débora Aparecida Ribeiro Campos relatou em juízo que:

Estava chegando com seu carro, na rua de sua casa, por volta de meio dia.

Estacionou o carro e ele bateu na janela e pediu para ela descer. Ela se negou e começou a buzinar para chamar atenção dos vizinhos. Ele mostrou a arma na cintura. Ela ficou com medo. Pegou a bolsa e a chave do veículo e subiu correndo, era uma ladeira. Pessoal já estava gritando para ela entregar a chave. Na hora ficou nervosa subiu correndo, lá no alto. Ele estava atrás delas e mandou ela jogar a chave senão ia atirar nela. Ela jogou. Ele pegou a chave e desceu com o carro. Não fez o reconhecimento na delegacia, somente por foto. O rapaz que estava na delegacia era outra pessoa. O reconhecimento por fotografia se deu uns 3 (três) dias depois do roubo. Eram 3 ou 5 fotos. Ela indicou quem era. Alguns dias depois foi localizado o carro em poder de terceira pessoa.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Nilton César Moreira da Silva declarou em juízo que:

Deparam com o veículo em Lorena, momento em que o condutor tentou fugir, mas foi detido e afirmou que quem entregou-lhe o carro foi o Pedro Henrique. Não ficaram sabendo se a vítima fez o reconhecimento do acusado. Que o nome do acusado era famoso no mundo policial, em que vários roubos de carro tinham como autoria o mesmo.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Zaqueu Siqueira Azarias disse em juízo que:

Estava em patrulhamento pelo Bairro da Cruz, quando foi informado de que uma viatura da Força Tática avistou um veículo furtado, mas o perdeu de vista. Então, ele e Nilton foram procurar o referido veículo, tendo encontrado e seguido, momento em que Wagner viu e apreendeu fuga, mas foi detido próximo ao posto Fama de Lorena. Disse que este afirmou que ia esconder o carro em Canas e que o automóvel foi deixado por Pedro para que ele usasse. Que Wagner é conhecido no meio policial por crimes de tráfico de drogas. Não ouviu o Pedro Henrique falar nada acerca do roubo do HB20.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Wagner Ramos argumentou em juízo que; Não conhece bem o réu, mas ele é roleiro de moto. Conta que o acusado deixou o carro em uma das ruas no Parque das Rodovias e disse que podia andar nele, que a chave estava no estepe, momento em que andou no referido automóvel e a polícia o parou depois de aproximadamente 25 minutos que estava dirigindo. O apelido do acusado é Chaleira.

Não tinha conhecimento de que o veículo estava com um adesivo cobrindo a placa. Não chegou a conversar com o Pedro sobre a procedência do veículo.

Por fim, interrogado, o réu PEDRO HENRIQUE CARVALHO BARBOSA alegou em juízo que: NÃO SE RECORDA DOS FATOS. INFELIZMENTE NÃO SE RECORDA. ESTAVA DESCONTROLADO, COM USO DE DROGAS.

Antes de analisar a prova oral colhida nos autos, cumpre tecer algumas considerações a respeito do reconhecimento fotográfico realizado em solo policial. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça colocou um fim ao entendimento de que as formalidades exigidas pelo art. 226, do CPP são apenas meras sugestões procedimentais.

O reconhecimento do suspeito de um crime por mera exibição de fotografias há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

O art. 226 do CPP admite o reconhecimento de pessoa e impõe o seguinte procedimento para sua validade:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao

lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Relator, o ministro Rogerio Schietti destacou que essas formalidades são essenciais para o processo.

O Superior Tribunal de Justiça então fixou as seguintes diretrizes:

1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime

2. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo

3. Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento

4. O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s), ao reconhecer, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a

confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua insita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua conseqüente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual

reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. STJ HC 598.886/SC. 6ª TURMA. REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. JULGADO EM 27/10/2020.

A técnica do mug shot ou foto de fichamento na delegacia, por sua vez, consiste na fotografia tirada do acusado no momento de sua prisão e, se mostradas a vítimas e testemunhas podem ter grande influência no reconhecimento devido à crença de que um indivíduo com um histórico de prisão terá mais chances de reincidir. Sobre o tema, Aury Lopes Jr. alerta, ainda, para o fato de que: “Não há dúvida de que o reconhecimento por fotografia (ou mesmo quando a mídia noticia os famosos “retratos falados” do suspeito) contamina e compromete a memória, de modo que essa ocorrência passada acaba por comprometer o futuro (o reconhecimento pessoal), havendo uma indução em erro.” (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 495.)

“É que o reconhecimento fotográfico torna vulnerável a formalidade prevista no artigo mencionado diante da substituição da comparação física pela comparação fotográfica, sendo considerado uma prova irritual por não seguir o procedimento. Igualmente, através da fotografia perde-se a amplitude favorecida pelo reconhecimento pessoal, pois há limitação quanto a identificação das características do indivíduo, bem como a imagem poderá estar desatualizada ou em preto e branco, dificultando a credibilidade.” (GOMES FILHO, A. M.; BADARÓ, G. H. R. I. Prova e Sucedâneos de Prova no Processo Penal Brasileiro. vol. 65/2007. p. 175-208. Revista Brasileira de Ciências Criminais, [S. l.], v. 65, 2007. Artigo consultado na Base de Dados RT Online mediante assinatura. Em pdf, p.1-22.)

“Outrossim, sob o ponto de vista prático, o reconhecimento fotográfico é normalmente adotado em Delegacias de Polícia pelo agente encarregado pela investigação. Nesta oportunidade, é exibido para o reconhecedor um álbum de fotografias – costumeiramente salvo no computador – no qual aparecem diversos indivíduos que foram apreendidos ou detidos anteriormente, cuja finalidade é propiciar que o reconhecedor aponte se algum dos indivíduos é o suposto autor do delito praticado contra si.

Há casos em que a autoridade policial apresenta o álbum de fotografias, antes da realização do reconhecimento pessoal ao reconhecedor, gerando um comprometimento da memória em virtude de um pré-juízo criado e, conseqüentemente, uma indução em erro para a realização do ato. A amostragem de fotografias cria uma memória fotográfica que pode acarretar danos irreversíveis, pois dificilmente a parte terá uma percepção diferente da visualizada e relatada.” (LOPES JR, A. Direito processual penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 494-495.)

Em brilhante trabalho realizada por Clarice Lessa de Fraga foi tecida alguns comentários a respeito das falsas memórias e o procedimento do reconhecimento fotográfico:

“O cérebro humano não armazena nenhuma imagem em forma de fotografia de qualquer coisa que tenhamos visualizado ou presenciado, como por exemplo, pessoas ou objetos. Explica-se isso em razão do problema que enfrentáramos pela falta de espaço na memória, tendo em vista que as pessoas recebem diversas informações ao longo da vida, não sendo possível armazená-las integralmente.

Diante disso, sabe-se que a realização do reconhecimento fotográfico através da amostragem de fotografias gera uma memória fotográfica no reconhecedor, pela qual haverá um confronto entre as lembranças do ato e as imagens apresentadas, sendo que dificilmente haverá um convencimento contrário da parte em razão da contaminação originada pelo efeito da indução. Isto ocorre porque a vítima/testemunha realiza o ato probatório com a convicção de que as autoridades somente lhe apresentam as fotografias por haver certeza de que o autor do delito está em alguma daquelas imagens. Todavia, não é o que ocorre na prática, porque a parte procura não frustrar a expectativa criada pela autoridade responsável, vindo a indicar aleatoriamente a imagem que 'mais' se aproxima das características do indivíduo. Por outra banda, através do reconhecimento fotográfico tem-se outro efeito deletério na memória, que é a redução da percepção de características que seriam detectadas caso o ato fosse realizado pessoalmente, considerando que o reconhecedor estará adstrito aos elementos constantes na imagem. Desta forma, resta prejudicada

a identificação de características específicas do acusado, pois há casos em que a imagem é somente de rosto, por exemplo, não sendo possível averiguar a altura, o porte físico, alguma expressão etc. Igualmente, salienta-se que através das fotos se tem uma representação estática, pela qual não há demonstração atual e integral das características do indivíduo a ser reconhecido. Por tais razões, no ato do reconhecimento será constatada as circunstâncias percebidas quando retirada a fotografia e não consoante o momento delituoso.

Conquanto, conforme referido anteriormente, as lembranças são o resultado de uma percepção passada, presente e futura. Deste modo, somente será possível a identificação do transgressor através de fotografias se a parte o conhecer, isto é, se a imagem do indivíduo estiver armazenada em sua memória. Caso contrário, quando da realização do reconhecimento pessoal, se houver, a imagem recordada será a apontada nas fotografias e não especificamente do rosto do autor do delito. Ademais, importante destacar, como visto, que há diversos fatores que corroboram à sugestionabilidade e à indicação errônea, como: a seleção de fotos de pessoas que não possuem características físicas semelhantes; a falta de simetria nos formatos das fotografias; a 'pressão' para que o reconhecedor aponte uma imagem; a convicção do reconhecedor acerca da autoria, porém, trata-se de falsas informações; a indicação de que os indivíduos apresentados são autores de crimes específicos cometidos em determinada localidade e de tal forma; entre outros.

Por tais motivos, o reconhecimento fotográfico não deve servir como único fundamento numa sentença condenatória, pois se trata de um ato fragilizado, que não segue um procedimento legal, e que depende exclusivamente da memória da parte, que poderá apresentar distorções naturais e/ou manipuladas. Além disso, não se deve olvidar que, por estar adstrito a uma imagem que reduz as características físicas do reconhecido, este meio de prova é ainda mais deficitário, motivo pelo qual se defende a necessidade de se provocar a atuação do Legislador de modo a estabelecer uma disciplina legislativa específica para esta modalidade de meio de prova a fim de que se estabeleça uma forma que reduza o número de erros e induções."

(A INFLUÊNCIA DAS FALSAS MEMÓRIAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CLARISSE LESSA DE FRAGA. Disponível em [clarice_fraga.pdf](#) (pucrs.br) - acesso em 16/09/2021)

Feitas essas considerações, cumpre ainda salientar algumas circunstâncias que enfraquecem ainda mais o arcabouço probatório e o ato de reconhecimento em si. Quando da lavratura do boletim de ocorrência, a vítima afirmou que: "afirmou não saber se teria condições de realizar o reconhecimento" (fl. 07)

No caso, posteriormente, a vítima reconheceu, de forma fotográfica (fl. 22) o acusado como sendo autor do delito.

Ocorre que não foram produzidos nenhum outro elemento de prova a respeito da autoria do réu, com ele não foi apreendido nenhum dos pertences subtraídos, o fato não foi presenciado por nenhuma outra testemunha.

Assim, a única prova contra o réu é o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, com seus amplos problemas e vícios acima citados.

Ao contrário do quanto sustentado pelo Ministério Público, não há qualquer característica distinta do acusado que possa dar subsistência ao reconhecimento fotográfico.

A autoria policial deveria ter, no caso, realizado o reconhecimento PESSOAL, seguindo os ditames exigidos na legislação processual.

Além disso, mais de 1 (um) ano após o fato, em juízo, a vítima não afirmou, com a certeza necessária, ser o acusado o autor do delito imputado.

Nota-se que o longo tempo transcorrido, sem sombra de dúvida, macula o ato de reconhecimento, uma vez que a memória humana vai perdendo, ao longo do tempo, elementos que poderiam indicar, com exatidão, o autor do delito apurado.

É certo que uma condenação criminal somente pode ocorrer quando apoiada em provas seguras, cabais e extensas de dúvidas, sendo que indícios isolados ou meras presunções, isoladamente consideradas, não constituem prova dotada dessas qualidades, sendo insuficientes para amparar um decreto condenatório. Ademais, os indícios que autorizam um juízo condenatório são apenas os concludentes e que conduzam a certeza e afastem qualquer hipótese favorável ao acusado (RT 218:96, RT 166:553). Isto porque o Direito Penal não opera conjecturas ou presunções, exigindo

prova segura e indubitosa da autoria delitiva. Feitas tais considerações, no caso, verifica-se que apesar de provada a materialidade delitiva, permanece dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Neste contexto, torna-se temerário considerar como elemento de prova o isolado reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mormente quando não ratificado, pessoalmente, no contraditório judicial.

Indiscutivelmente, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi claramente irregular e não obedeceu às mínimas formalidades legais. Importante frisar, neste ponto, que, por fatores de ordem técnica, os traços fisionômicos são facilmente alteráveis através de fotografias. Desta forma, ainda que admissível como meio de prova, este deve ser visto com extrema ressalva, não podendo ser aceito, máxime quando isolado e, sobretudo, quando não se sabe se a fotografia foi mostrada diretamente ou selecionada espontaneamente pela vítima em álbum fotográfico. Por tais motivos, o reconhecimento fotográfico tem, lamentavelmente, propiciado os mais lamentáveis enganos, levando à prisão, muitas vezes, pessoas que, posteriormente, se vieram reconhecer totalmente inocentes (RT, 165/565). Sobre o tema, a preciosa lição contida no julgado do extinto TACRIM, de relatoria de ALBERTO SILVA FRANCO, nos autos da Apelação nº 126.084: "Reconhecimento fotográfico. Embora inquestionável o reconhecimento fotográfico como meio de prova, existe risco neste procedimento, porque não se pode desprezar o fenômeno psicológico da 'atenção expectante' que age como poderosa auto-sugestão a influenciar o reconhecedor. Assim, para se preservar o valor probante do ato, aquele deve previamente efetuar uma descrição dos traços fisionômicos e dos aspectos fisionômicos, retidos em sua memória, da pessoa a ser reconhecida". Por outro lado, não havendo reconhecimento pessoal em juízo, inviável amparar um decreto condenatório com base nos elementos colhidos em sede inquisitorial. Diante disso, sendo frágil, conflitante e contraditório o quadro probatório, inadmissível se mostra o decreto condenatório, tornando imperiosa a absolvição do acusado, vigorando na hipótese o princípio "in dubio pro reo".

Cumpra salientar que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo pode afirmar, com certeza, ser o réu o autor do delito que lhe é imputado.

Em que pese eventual gravidade dos fatos imputados, isto não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil. Nisto consiste o mandamento de otimização contido no princípio do in dubio pro reo.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o acusado PEDRO HENRIQUE CARVALHO BARBOSA da imputação do cometimento de crime descrito na denúncia art. 157, §2º-A, I, do CP.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado.

Comunique(m)-se ao(s) ofendido(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 25 de fevereiro de 2022.